

분절된 고용구조에서의 ‘교섭단위 결정’과 ‘교섭의무의 범위’에 관한 연구

— NLRA의 공동사용자 및 혼합 교섭단위를 소재로 —

권 오 성*

목 차

- I. 서론
- II. 미국 NLRA상 공동사용자와 혼합 교섭단위
- III. 사용자성과 단체교섭의무의 단계적 해석 모델
- IV. 결론

I. 서론

균열 일터(fissured workplace) 현상의 확산은 현행 단체교섭 체계의 고전적 전제인 “직접고용 - 단일사용자 - 단일 교섭구조”를 지속적으로 침식하고 있다. 특히 사내하도급, 외주화, 파견, 모자(母子) 회사를 포함한 기업집단화, 프랜차이즈, 플랫폼 기반 거래가 확대되면서, 형식상 고용계약의 당사자가 존재하더라도 근로조건의 결정이 도급인(소위 ‘원청’), 모회사, 프랜차이즈 등 형식상 고용계약의 당사자 이외의 제3자에 의해 실질적으로 좌우되는 사례가 늘어났다. 이러한 상황에서 ‘사용자’를 형식적 계약구조에 과도하게 연동시키면, 단체교섭은 실효성을 상실하고 부당노동행위에 대한 구제는 책임의 공백을 낳게 된다.

투고일 2026. 2. 15., 심사일 2026. 3. 3., 게재확정일 2026. 3. 7.

* 연세대학교 법학전문대학원 교수

미국 NLRA상 공동사용자(joint employer) 논쟁은 이러한 구조적인 불일치가 집단적 노사관계법 내부에서 어떠한 방식으로 표면화될 수 있는가를 압축적으로 보여준다. 특히, NLRB의 2015년 Browning-Ferris 결정은 ‘간접적 통제’와 ‘유보된 통제권’을 공동사용자의 판단요소로 끌어들이며 ‘누가 사용자인가?’라는 논쟁을 재점화하였다. 반면, 이후의 NLRB의 일련의 규칙(rule) 제정과 해당 규칙에 관한 사법(司法) 심사는 NLRB의 공동사용자 판단기준이 코먼로상 대리(agency) 기준을 일탈하는지, 그리고 NLRB의 규칙 제정이 예측가능성을 훼손하는지라는 쟁점을 중심으로 상이한 입장을 취하였다. 이 과정에서 NLRB의 2023년 최종 규칙은 연방지방법원에 의해 무효로 판단되었고, NLRB가 항소를 자진 취하함에 따라 실무상 2020년 규칙이 공동사용자 판단의 기준으로 기능하게 되었다.¹⁾

우리나라의 경우에도 하도급, 프랜차이즈, 플랫폼 등 분절된 고용구조의 확대에 인하여 관련 근로자의 ‘형식적’ 사용자가 해당 근로자의 근로조건에 관한 결정권을 ‘실질적’으로 행사할 수 없게 되는 현상이 증가하였다. 이러한 상황은 단체교섭의 기능부전을 초래하고 있으며, 이는 결국 관련 근로자의 근로조건의 열화(劣化)로 연결되고 있다. 2025년 9월 9일 공포된 개정 노동조합법(이하 편의상 “2025년 개정법”이라고 한다)은 이러한 문제에 대응하기 위하여, 동법 제2조 제2호 후단(後段)으로 “이 경우 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라는 규정을 추가하였다. 이러한 개정 규정은 2026. 3. 10. 그 시행이 예정되어 있다. 따라서, 위 개정 규정에 따른 노동조합법상 ‘사용자성의 확장’을 어떻게 해석·운용할 것인지가 실무상 급박한 과제로 부상하였다. 필자는 이러한 개정 규정이 분절된

1) NLRA상 공동사용자 범리에 관한 최근의 전개과정에 관한 국내 논의로는 강주리, “미국 연방노동관계법상 공동사용자 지위 결정에 관한 규칙 개정의 의미 - 초기업별 교섭에서 사용자 지위 및 교섭의무 판단을 둘러싼 쟁점을 중심으로 -”, 『산업관계연구』 제34권 제2호, 2024 및 이태현, “미국 공동사용자 범리의 현황과 시사점 - 브라우닝 펠리스 결정과 그 이후의 전개를 중심으로 -”, 『노동법학』 제86호, 2023 참조.

고용구조에서의 단체교섭의 기능부전 문제를 해결하기 위한 중요한 입법적 성취라고 생각한다. 다만, 위 규정에 따른 사용자 범위의 확장이 곧바로 실질적 사용자에게 ‘전면적 교섭의무’를 부과한다거나 또는 형사책임의 자동적 확대로 이어진다고 해석될 수는 없다. 위 규정 자체가 “그 범위에 있어서는 사용자로 본다”라고 규정하여 실질적 사용자의 교섭의무 및 부당노동행위 책임의 제한을 예정하고 있기 때문이다. 따라서, 위 규정의 해석·운용에 관해서는 사용자성 자체의 확대 기준뿐 아니라 단체교섭의무와 부당노동행위 책임의 귀속구조를 단계적으로 설계하는 정교한 해석 작업이 요구된다.

이 글은 2025년 개정 노동조합법 제2조 제2호 후단에 따른 사용자성 확장을, 사용자 개념 단계가 아니라 법률효과 단계에서 조정하는 해석 모델을 제시함을 목적으로 하며, 이를 위해 미국 NLRA상 공동사용자 및 혼합 교섭단위 논의를, 실체 기준이 아니라 교섭의무 배분 논리로 재구성하여 비교법적 시사점을 도출하고자 한다. 물론, 이는 미국의 공동사용자 법리를 우리나라에 기계적으로 이식하고자 하는 것은 아니다. 필자의 구상은 미국의 공동사용자 및 혼합 교섭단위 관련 논의를 ‘사용자 해당 여부’라는 단일한 질문으로 환원하지 않고, 사용자성의 확장이 가져오는 법적 효과를 단체교섭의무와 부당노동행위 책임의 귀속구조로 분해하여 분석하는 것이다. 이를 통하여 2025년 개정법이 예정하는 사용자성의 확장이 곧바로 전면적 교섭의무 및 부당노동행위 책임의 일괄적인 확대로 연결되지 않도록 하는 해석을 모색한다.

이를 위하여 이 글에서는 먼저 미국 NLRA상 공동사용자 및 혼합 교섭단위와 관련한 법리의 전개 과정을 살펴보고(제II장), 다음으로 2025년 개정법 제2조 제2호 후단과 관련하여 ‘사용자 지위-단체교섭의무-부당노동행위 책임’이 자동적으로 연결되는 단선적(linear) 해석 모델을 대신하여, 사용자성 확장 이후 법률효과의 단계에서 그러한 사용자가 부담하는 단체교섭의무와 부당노동행위 책임을 해당 규범의 규범목적에 따라 제한하는 단계적(tiered) 해석 모델을 제시한다(제III장).²⁾ 다만, 이

2) 국내에서도 사내도급 구조에서 사용자성 문제는 형식적 계약관계의 문제가 아니라, 근로조건 결정권과 책임 귀속의 실질적 소재를 기준으로 재구성되

글의 범위는 실질적 사용자가 부담하는 단체교섭의무의 범위로 하고, 부당노동행위 책임에 관한 논의를 후속연구의 과제로 남긴다. 마지막으로, 결론에서는 ‘한국형’ 공동사용자 논의의 방향을 제시한다(제IV장).

II. 미국 NLRA상 공동사용자와 혼합 교섭단위

1. 미국 NLRA 공동사용자 법리

1) 공동사용자 인정 기준의 변천

(1) 공동사용자 법리의 연원(淵源)

NLRA상 공동사용자 문제는 NLRA에 따른 대표선거·교섭구조 및 부당노동행위 책임을 포함하여, 두 개 이상의 사업자가 특정 근로조건을 공유하거나 공동으로 결정하는지 여부에 따라 복수의 기업 모두를 ‘사용자’로 평가될 수 있는지를 식별하는 문제이다.

최근의 균열된 일터 상황에서 공동사용자 문제가 중요한 쟁점으로 부각되고 있는 것은 사실이지만, 이러한 문제는 아주 새로운 것이 아니다. 오히려 미국의 제조업 초기에는 사용자가 신발과 같은 제품의 생산 과정 일부를 독립적인 장인(craftsmen)에게 외주로 맡기는 경우가 흔했다. 이후 의류 산업에서는 생산 과정의 일부를 중간 매개 생산자에게 하도급 주는 유사한 관행이 확산되었고, 이는 종종 개수 임금(piece rate) 방식의 스웨트숍(Sweatshop, 착취 작업장) 생산으로 이어졌다.³⁾

이에 NLRB는 설립 초기부터 제3의 기업이 다른 사업체에 고용된 개인들의 근로조건에 영향을 미치거나 이를 통제하는 상황에 직면해 왔다. NLRB가 이러한 공동고용 상황을 처음으로 다룬 것은 1936년 Bell Oil

어야 한다는 점이 이미 지적된 바 있다. 김미영, “사내도급 고용관계에서 부당노동행위 책임 - 미국 공동사용자 원리와 비교 -”, 『노동법포럼』 제 21호, 2017 참조.

³⁾ Douglas E. Ray, Robert N. Strassfeld & Ariana R. Levinson, Understanding Labor Law 16 (5th ed. 2019).

& Gas Co 결정⁴⁾이다. 이 사건은 석유 생산과 관련된 재압력(repressure) 시설 운영에 관한 것으로, Bell Oil & Gas Company를 포함한 세 개의 회사가 공동으로 소유한 재압력 공장(repressure plant)의 근로자들에 관한 사건이었다. NLRB는 이 사건에서 재압력 공장이 Bell과 다른 두 회사(Reno와 Burke-Divide)에 의해 공동 소유되었지만, 공동 소유자 간 합의에 따라 Bell이 근로자들을 실질적으로 고용하고 감독했으므로, Bell을 사용자(employer)로 인정했다. 다만, 이 결정이 세 회사를 공동사용자로 인정한 것은 아니며, 공동 소유·공동 사업 구조 하에서 ‘실질적 사용자 식별’을 시도한 초기 사례로서, 이후 공동사용자 법리의 출발점으로 사후적으로 재해석되는 의미를 가진다. 한편, 이러한 결정에 대하여 제5 순회 항소법원은 1937년 NLRB의 결정을 지지하며 집행 명령을 내렸다.⁵⁾ 한편, NLRB에서 공동고용이 실질적인 쟁점이 된 사건을 처음으로 판단한 것은 1940년 American Bemberg Corp. 결정⁶⁾으로, 이 사건은 교섭단위 결정 사건이었다. 이 사건에서 NLRB는 American Bemberg Corporation과 North American Rayon Corporation이라는 두 개의 별도의 법인이 동일한 부지 내에서 인접하여 운영되었고, 유지보수(maintenance) 부서가 두 회사에 공통으로 서비스를 제공하고 있었으며, 두 회사는 고위 경영진과 노무관리 정책을 상당 부분 공유하고 있었다는 점을 근거로 이들을 하나의 교섭단위로 결정하였다. 다만, 이 결정이 공동사용자 개념을 명시적으로 긍정한 것은 아니며, 오히려 현대적 관점에서 보면 두 회사를 ‘단일 사용자(single employer)’로 보려는 입장에 가깝다. 따라서, 이 결정은 단일사용자와 공동사용자 개념의 구분이 명확하지 않았던 초기 사례로 평가할 수 있다.

한편, NLRB는 1943년 Bethlehem-Fairfield Shipyard, Inc. 결정⁷⁾에서 Bethlehem-Fairfield가 구내식당 운영업체와 별개 계약관계에 있었음에도, 구내식당 근로자에 대한 해고 및 임금스케일 설정과 관련한 유보된

4) Bell Oil & Gas Co., 1 N.L.R.B. 562 (1936).

5) National Labor Relations Board v. Bell Oil & Gas Co., 91 F.2d 509 (5th Cir. 1937).

6) American Bemberg Corp., 23 N.L.R.B. 623 (1940).

7) Bethlehem-Fairfield Shipyard, Inc., 53 NLRB 1428 (1943).

권한을 근거로 공동사용자성을 인정하였다. 이 결정은 NLRB가 공급·서비스업체에 대한 ‘유보된 권한(reserved authority)’을 통해 도급인이 구내식당 근로자에 대한 통제를 행사할 수 있다는 점을 인정한 사례로, 공동사용자 개념을 명시적으로 인정한 초기 사례 중 하나로 평가된다.

1964년 *Boire v. Greyhound Corp.* 사건⁸⁾은 NLRB가 Greyhound와 하청업체 Floors를 공동사용자로 인정한 것에 대한 지방법원의 금지명령을 취소한 판결이다. 이 사건은 대표선거가 문제된 사건으로, NLRB는 Greyhound의 터미널 관리자들이 하청업체인 Floors의 감독관들과 협의하여 작업 일정을 수립하고 해당 일정을 충족하는 데 필요한 직원 수를 결정한다는 점, Floors의 감독관들은 Greyhound의 터미널을 불규칙적으로 방문할 수 있으며 때로는 최대 이틀 동안 나타나지 않을 수도 있다는 점, 근로자들이 Greyhound 터미널 담당자로부터 작업 지시를 받는다는 점 및 Greyhound가 한 번은 불만족스러운 근로자를 해고하도록 지시했다는 점에 근거하여 Greyhound와 Floors가 공동사용자 관계에 있다고 결정하고, 대표 선거를 명령하자,⁹⁾ Greyhound가 미국 플로리다 남부 지방 법원에 선거 금지를 구하는 금지명령(injunction)을 신청하였다. 이러한 신청에 대하여 지방법원이 선거를 영구적으로 금지하는 명령을 내렸고,¹⁰⁾ 항소심인 제5순회 항소법원도 이를 승인하였다.¹¹⁾ 이에 연방대법원은 공동사용자 여부를 본안에서 판단하지 않고, NLRB가 통제의 공유 여부를 사실관계로 판단하는 것이 합법적이라는 점을 전제로 지방법원의 사전적 금지명령을 허용하지 않았다. 다만, 이러한 판결은 NLRB의 사실판단 영역을 존중하는 방향의 판결로, 공동사용자 개념 자체를 창설·승인한 것은 아니었다.

이후 제3순회구 연방항소법원의 1982년 *NLRB v. Browning-Ferris Industries of Pennsylvania* 판결¹²⁾은 계약관계가 없는 사용자라 하더라도

8) *Boire v. Greyhound Corp.*, 376 U.S. 473 (1964).

9) *Nat'l Labor Relations Bd.*, Case No. 12-RC-1209.

10) *Greyhound Corporation v. Boire*, 205 F. Supp. 686 (S.D. Fla. 1962).

11) *Harold A. Boire, Regional Director, Twelfth Region, National Labor Relations Board, Appellant, v. the Greyhound Corporation, Appellee*, 309 F.2d 397 (5th Cir. 1962).

특정 근로자 집단에 대해 공동사용자(joint employer)로 간주되어 사용자에게 해당할 수 있는지 여부를 판단하는 전통적인 견해를 정리하였다.¹³⁾ 이 사건에서 Browning-Ferris Industries of Pennsylvania는 펜실베이니아에서 쓰레기 하차장을 운영하며, 수거된 쓰레기를 최종 매립지로 운송하는 회사였는데, NLRB는 Browning-Ferris Industries of Pennsylvania이 자신과 운송 중개업체가 공동으로 고용한 운전기사 3명을 해고함으로써 NLRA § 8조(a)(1)에 따른 부당노동행위를 범하였다고 결정하였다.¹⁴⁾ 이후 제3연방항소법원은 NLRB의 결정을 지지하며 집행판결을 내렸다. 제3연방항소법원의 판결에 따르면, 사용자는 근로자의 사용자와 함께 고용의 본질적 조건과 내용을 규율하는 사항을 공유(share)하거나 공동으로 결정(co-determine)하는 경우 공동사용자로 평가될 수 있으며, 이 경우 문제의 핵심은 문제된 공동사용자가 다른 사용자에 의해 고용된 근로자들의 고용조건과 내용에 대해 충분한 통제를 가지고 있었는지 여부였다.¹⁵⁾ 한편, 이 판결을 통해 ‘단일사용자(single employer)’와 ‘공동사용자(joint employer)’의 개념이 명확하게 구분되었다. 이 판결 이전에는 위 두 개념이 혼용되는 경우가 있었으나, 이 판결을 통하여 ① 복수의 법인이 외견상 별개이나 실제로는 하나의 통합된 기업인 경우를 단일사용자로, ② 두 회사가 완전히 별개의 법인이고 운영도 독립적이지만, 특정 근로자 집단에 대해서만큼은 통제권을 공유하는 경우를 공동사용자로 구별하는 것이 정식화되었다.

(2) 1980년대 중반 이후 공동사용자 기준의 엄격화

NLRB는 1984년 TLI Transportation Ltd. 사건¹⁶⁾에서 1982년 제3연방항소법원의 Browning-Ferris 판결이 제시한 ‘공동 결정(co-determination)’

¹²⁾ NLRB v. Browning-Ferris Industries of Pennsylvania, Inc., 691 F.2d 1117 (3d Cir. 1982).

¹³⁾ National Labor Relations Board, Petitioner, v. Browning-Ferris Industries of Pennsylvania, Inc., Respondent, 691 F.2d 1117 (3d Cir. 1982).

¹⁴⁾ Browning-Ferris Industries of Pennsylvania, Inc., 259 NLRB 148 (1981).

¹⁵⁾ 691 F.2d 1117, 1123.

¹⁶⁾ TLI, Inc., 271 NLRB 798 (1984).

의 범위를 매우 협소하게 해석하여, 사용사업주의 지시가 ‘운영상의 필요’에 의한 것이라면 사용자성을 부정하는 경향을 만들었다. 이 사건은 인력파견업체인 TLI, Inc.와 사용사업주인 Crown Zellerbach Corp.가 NLRA상 공동사용자인지 여부가 문제된 사건으로, NLRB는 Crown사가 운전기사들에게 배차 지시를 하고 안전 수칙을 준수하게 한 것은 사실이나, 이는 ‘일상적이고 제한적인(routine and limited)’ 수준의 통제에 불과하다는 점을 이유로 Crown사의 공동사용자성을 부정했다. 이 결정으로 NLRA상 공동사용자로 인정되기 위해서는 단순히 영향을 미치는 정도가 아니라, 근로조건에 대해 ‘직접적이고 즉각적인(immediate and direct)’ 통제를 행사해야 한다는 엄격한 기준을 제시되었다. 또한, NLRB는 같은 해 Laerco Transportation 사건¹⁷⁾에서는 공동사용자로 인정되기 위해서는 잠재적 공동사용자가 “고용 관계와 관련된 사항, 즉 채용(hiring), 해고(firing), 징계(discipline), 감독(supervision), 업무 지시(direction) 등에 의미 있는 영향(meaningfully affects)을 미쳐야 한다고 판시하였다.

이들 결정은 2015년 Browning-Ferris Industries of California, Inc. 결정에서 명시적으로 폐기되기 전까지 ‘TLI/Laerco 기준’으로 불리며 공동사용자 인정 범위를 상대적으로 좁게 제한하는 역할을 하였다.

(3) 2015년 이후의 상황

전술한 1984년 TLI 결정 및 Laerco 결정 이후 30여년간 NLRA상 공동사용자로 인정되기 위해서는 일반적으로 사용자가 근로조건의 특정 요소에 대해 ‘실제로 그리고 직접적으로(actually and directly)’ 통제하고 있다는 점이 요구되었다. 그러나 NLRB는 2015년 Browning-Ferris Industries of California 사건¹⁸⁾에서 TLI/Laerco 기준을 폐기하고, 어떤 주체가 근로조건에 대해 ‘간접적(indirect)’이거나 또는 ‘잠재적인(potential)’ 통제만을 가지고 있더라도 공동사용자에 해당할 수 있다는 견해를 취하였다.

위 결정에서 NLRB 다수의견은, 1982년 제3연방항소법원의 Browning-Ferris 판결이어서 채택한 접근¹⁹⁾을 재도입하고, 1984년 이후 그러한 접

¹⁷⁾ Laerco Transportation, 269 NLRB 324 (1984).

¹⁸⁾ Browning-Ferris Industries of California, Inc., 362 N.L.R.B. 186 (2015).

근에서 이탈했던 여러 NLRB 결정들을 배척한다고 판시하였다. 나아가, 공동고용 관계의 존재 여부를 판단하기 위해 검토해야 할 사항들을 비 한정적 목록(non-exhaustive list)으로 제시하였는데, 여기에는 근로자의 채용, 해고, 징계, 감독, 배치 및 지휘에 관한 권한, 제공될 근로자의 수를 정할 권한, 근무일정, 근속, 연장근로에 대한 통제, 그리고 업무 수행의 방식과 방법을 결정할 권한 등이 포함되었다.²⁰⁾ 또한, 다수의견은 “더 이상 공동사용자가 근로조건에 대한 통제권을 보유할 뿐만 아니라 실제로 그 권한을 행사해야 한다고 요구하지 않겠다. 행사되지 않은 경우라 하더라도 근로조건을 통제할 수 있는 유보된 권한(reserved authority)은 공동고용 판단에서 분명히 관련성이 있다. 또한 공동고용 판단에서 의미를 갖기 위해 법정상의 사용자의 통제가 직접적이고 즉각적으로 행사되어야 한다고 요구하지도 않겠다. 다른 요건들이 충분하다면, 중개자를 통한(through an intermediary) 간접적인 통제 역시 공동사용자 지위를 성립시킬 수 있다.”고 강조하였다²¹⁾

한편, 위 다수의견은 결정문의 각주를 통해 “근무조건에 대한 직접적 통제, 간접적 통제, 그리고 잠재적 통제는 모두 공동고용 판단에서 관련성을 가진다는 데 사무총장(General Counsel)과 의견을 같이한다”고 하여 ‘잠재적’ 통제도 언급하였다.²²⁾ 다수의견과 반대의견은 이러한 접근이 코먼로와 합치하는지 여부를 두고 의견이 갈렸다. 다수의견에 따르면, 공동사용자의 통제가 ‘실제로 행사되어야 하고 그 행사가 직접적이고 즉각적이어야 한다’는 요구는 코먼로에 의해 강제되는 것이 아니며, 오히려 코먼로 원칙과 일관되지 않는 것으로 보인다고 보았다.²³⁾ 이에 대해 반대의견은, 코먼로 원칙에서 말하는 ‘통제’는 ‘일정한 직접적이고 즉각적인 통제’를 요구한다고 반박했다.²⁴⁾

이후, 도널드 트럼프 대통령 취임(1기) 이후 NLRB가 취한 최초의 조

19) 691 F.2d 1117, 1122-23 (3d Cir. 1982).

20) Browning-Ferris Indus. of Cal., 362 N.L.R.B. No. 186, at 19.

21) Id. at 2.

22) Id. at 16 n.68.

23) Id. at 17 (majority opinion).

24) Id. (Miscimarra & Johnson, dissenting).

치 가운데 하나는 2015년 Browning-Ferris 결정을 반복하는 것이었다. NLRB는 2017년 11월 Hy-Brand Industrial Contractors 사건²⁵⁾에서 공동고용을 인정하기 위해서는 직접적이고 실제적인 통제가 입증되어야 한다는 기준으로의 복귀를 선언했다. 그러나, NLRB는 2018년 2월 해당 결정에 관여한 위원 가운데 한 명이 회피(recusal)했어야 했다는 이유로 Hy-Brand 결정을 취소했다.²⁶⁾

이후 NLRB는 2018년 9월 위 Hy-Brand 결정보다도 제한적인 내용의 제안 규칙(Proposed Rule)을 발표하였다. 이에 따르면 공동고용 지위를 인정하기 위해서는 ‘사용자가 다른 사용자의 근로자에 대해 제한적이고 일상적인 수준을 넘는 상당한 직접적 통제를 보유하고 실제로 행사해야 한다’.²⁷⁾ 이는 직접적이고 실제적인 통제를 다시 요구할 뿐만 아니라, ‘상당한(substantial)’이라는 표현과 ‘제한적이고 일상적인 수준이 아닌(not limited and routine)’이라는 문구를 추가한 것이다.

한편, 미국법률협회(American Law Institute)는 2018년 고용법 리스테이트먼트 제3판(Restatement (Third) of Employment Law)의 최종본을 공개하였는데, 동 리스테이트먼트는 공동사용자를 성립시키는 데 어떠한 유형의 ‘통제’가 필요한지에 대해서는 아무런 기준도 제시하지 않았다. 이 리스테이트먼트 § 1.04(b)는 “개인은 (i) 적어도 하나의 사용자에게 노무를 제공하고, (ii) 그 사용자와 다른 공동사용자들이 각각 § 1.01(a)(3)에 규정된 바와 같이 그러한 노무 제공을 통제하거나 감독하는 경우, 두 명 이상의 공동사용자의 근로자에 해당한다”고 규정한다. 그러나 이 문언이나 리스테이트먼트의 주석과 해설 어디에서도 ‘직접적·실제적’ 통제와 ‘간접적·잠재적’ 통제 사이의 문제를 다루지 않는다.²⁸⁾

이후 2018년 12월 D.C. 연방항소법원은 본질적으로 2015년 Browning-

25) Hy-Brand Indus. Contractors, Ltd., 365 NLRB No. 156 (2017).

26) Hy-Brand Indus. Contractors, Ltd., 366 NLRB No. 26 (2018).

27) National Labor Relations Board, “The Standard for Determining Joint-Employer Status,” 29 CFR Chapter I RIN 3142-AA13 (Sept. 2018), 1.

28) Charlotte Garden and Joseph Slater, *Comments on Restatement of Employment Law (Third) Chapter 1*, 27 Employee Rts. & Employment Policy J. 265, 266-78 (2018).

Ferris 결정을 유지하는 판결을 하였다.²⁹⁾ 즉, 이 판결에서 D.C. 연방항소법원은 NLRA상 ‘사용자’의 정의, 공동고용 규칙을 포함하여, 코먼로를 따라야 하며, 이러한 코먼로 영역에서는 법원이 NLRB의 해석에 대해 어떠한 존중(deference)도 할 필요가 없다고 판시하고, 나아가 임금, 근로시간, 근로조건에 대한 ‘간접적’ 통제와 ‘유보된(reserved)’, 즉 잠재적 통제 역시 공동사용자 지위를 성립시킬 수 있다는 점이 코먼로에서 이미 확립되어 있다고 설명했다.

한편, 2020년 NLRB는 2015년 Browning-Ferris 결정을 폐기하고, 공동사용자 지위 판단에 있어 ‘직접적이고 즉각적인 통제(substantial direct and immediate control)’를 다시 핵심 기준으로 삼는 새로운 규칙을 공포했다.³⁰⁾ 동 규칙은 공동사용자로 인정되려면 고용주가 ‘핵심적인 고용 조건’ 중 하나 이상에 대해 ‘실질적인 직접적이고 즉각적인 통제’를 보유하고 행사해야 한다고 규정했다. 여기서 ‘핵심적인 고용 조건’은 임금, 복리후생, 근로시간, 채용, 해고, 징계, 감독 및 지시로 한정되었고, 간접적 통제, 계약상 유보되었으나 행사되지 않은 통제, 산발적·고립적·미미한 실제 통제만으로는 공동사용자 지위를 부여하지 않는다고 명시했다.

바이든 대통령 취임 후 NLRB는 2023년 공동사용자 판단 기준에 관한 규칙 개정안을 입법 예고했다.³¹⁾ 이 개정안은 2020년 규칙을 변경하는 것으로, 타인이 고용한 근로자의 고용 관계 핵심 사항 중 어느 하나에 대해 통제권을 보유하거나 행사한 경우 공동사용자로 인정하며, 유보된 통제권이나 간접적 통제도 고려한다고 명시했다. 그러나 텍사스 연방지방법원(E.D. Texas)은 이 규칙을 무효(vacate)로 판단했고,³²⁾ NLRB는 항소를 제기했다가 자진취하로 종결되었다.³³⁾

29) Browning Ferris Industries of California v. National Labor Relations Board, 911 F.3d 1195 (D.C. Cir. 2018).

30) Standard for Determining Joint-Employer Status, 85 Fed. Reg. 11,184 (Feb. 26, 2020) (codified at 29 C.F.R. § 103.40).

31) Standard for Determining Joint-Employer Status, 88 Fed. Reg. 73,946 (Oct. 27, 2023).

32) Chamber of Com. of the U.S. v. NLRB, No. 6:23-cv-00553, slip op. (E.D. Tex. Mar. 8, 2024).

33) Notice of Appeal (filed May 7, 2024); Motion for Voluntary Dismissal &

2) 법원론의 관점에서의 평가

우리나라에서 NLRA상 공동사용자 법리에 대한 관심은 주로 2015년 Browning-Ferris 결정이 제시한 간접적 통제(indirect control)와 유보된 권한(reserved authority)이라는 사용자성 긍정의 ‘실체적 기준’의 수용 가능성에 초점을 맞추어 왔다. 그러나 2015년 Browning-Ferris 결정 이후 10년간 공동사용자와 관련한 법리의 전개는 공동사용자성 긍정의 실체적 기준이 무엇인가를 넘어 그러한 기준이 어떠한 절차와 형식으로 정립되며, 또한 미국의 법체계상 어떠한 위계에서 구속력을 갖는가라는 ‘권한과 위계’의 문제와 큰 관련이 있다. 따라서, NLRA상 공동사용자 법리에 대한 비교법적 분석을 위해서는 관련 기준이 어떠한 법적 위계에서, 어떠한 방식으로 존재하는가를 살펴볼 필요가 있다.

이와 관련하여, NLRA상 공동사용자 여부의 판단은 ① 코먼로상 통제 기준(control test), ② NLRB의 규칙제정권에 근거한 규칙(rule), ③ NLRB의 개별 사건에 관한 결정(decision)의 세 가지 층위의 원천(source)이 결합된 결과로 나타난다. 2015년 Browning-Ferris 결정은 ③의 예이고, 2020년 최종 규칙(2020 joint employer final rule)은 ②의 예이다. 한편, ①은 NLRB의 이러한 결정과 규칙에 대한 법원의 사법통제의 준거로 기능한다.

상세히 보면, 먼저 NLRA상 공동사용자 판단기준에 관한 최상위의 법원(法源)은 코먼로상 통제 기준(위 ①)이다. NLRA의 핵심 개념은 코먼로상 대리(agency) 원리의 영향을 받아 해석되어 왔고, 공동사용자 논쟁도 결국 통제(control) 개념의 코먼로적 외연을 어디까지로 볼 것인지의 문제로 재구성된다. 따라서, 공동사용자 관련 논쟁에서 ‘간접적 통제·유보된 권한’ 표지의 수용 여부에 대한 입장이 격렬하게 충돌하는 것은 기본적으로 해당 표지가 코먼로상 통제 기준의 한계 내에 있는가에 대한 관점의 차이로 이해할 수 있다.

다음으로, ② 규칙(rule)은 NLRB가 일반적·추상적 기준을 설정하는 법형식이다. NLRB는 2020년 규칙으로 ‘실질적·직접적·즉각적 통제

(substantial direct and immediate control)를 보유하고(possess) 또한 행사할 것(exercise)’을 요구하는 기준을 제시하였고, 이후 동 규칙은 연방규정집(Code of Federal Regulations, 이하 “C.F.R.”라고 한다)에 편입(codification)되었다. 한편, NLRB는 개별 사건에 대한 결정(위 ③)을 통해 기준을 형성하기도 하는바, 2015년 Browning-Ferris 결정과 2017년 Hy-Brand 결정 등이 이에 해당한다. 다만, 이러한 결정은 규칙과 달리 일반적 구속력의 범위가 해당 사건의 사실상 맥락으로 제한되므로, 규칙이 존재하는 경우 NLRB는 ‘원칙적’으로는 해당 규칙에 따라 사건을 판단한다.

한편, NLRB의 규칙(위 ②)과 결정(위 ③)에 대한 연방법원의 사법심사는 상이한 경로를 따른다. NLRB의 결정은 구체적인 사안에 관한 ‘사실인정’과 그러한 사실에 대한 법적용의 결합으로 구성되며, 이러한 개별 ‘결정’은 주로 집행·구제의 국면에서 연방항소법원의 심사를 받게 된다. 이때, NLRB의 사실인정은 ‘실질적 증거(substantial evidence)’ 기준에 따라 상당한 존중을 받는다. 다만, 법 적용 측면에서는 코먼로상 통제 기준의 일탈 여부를 심사한다. 반면, 규칙에 관해서는 연방법원이 그러한 규칙 제정의 행정법적 절차와 이유제시의 적정성을 전면적으로 심사한다. 즉, NLRB가 제정한 규칙은 행정절차법(APA)에 따라 절차의 적법성과 이유제시의 합리성(reasoned decisionmaking)을 전면적으로 심사받으며, 그 내용이 자의적이거나 변덕스러운지(arbitrary and capricious) 여부가 핵심 심사기준이 된다. 실제로 텍사스 연방지방법원(E.D. Texas)이 NLRB의 2023년 최종 규칙을 무효로 판단한 것은, 해당 기준의 내용이 코먼로상 대리 기준의 한계 내에 있는가라는 실체적 판단 외에 해당 규칙 제정에 요구되는 절차적 요건의 충족 여부가 결합된 결과이다.

따라서, NLRA상 공동사용자 기준은 하나의 확정된 실체적 규범이 아니라, 코먼로라는 상위 준거, 규칙(rule) 제정이라는 일반적 규범의 형식, 개별 사건에 대한 결정의 형식 및 규칙과 결정을 심사하는 연방법원의 통제 양식의 상호 교차를 통해 형성된 것이다. 이러한 맥락을 고려할 때, 최근 10여년 동안 미국에서 전개된 공동사용자 인정 기준에 관한 거듭된 태도 변화를 올바르게 이해하기 위해서는 관련 기준이 생성되는

법형식과 그 법적 위계를 함께 고려할 필요가 있다. 따라서, NLRA상 공동사용자 법리를 통해 얻을 수 있는 비교법적 시사점은 ‘공동사용자의 판단 기준이 무엇인가?’라는 정태적인 사용자성 판단기준을 넘어 그러한 사용자성 확장의 효과를 어떠한 규범형식과 어떤 통제 가능성 아래에서 분배할 것인가라는 설계 문제를 포함한다.

2. 혼합 교섭단위 법리

1) 공동사용자와 혼합 교섭단위

NLRA상 혼합 교섭단위(mixed bargaining units)이란 단일 사업장 내에 다양한 사용자에게 의해 고용된 근로자 또는 여러 유형의 근로자 집단이 함께 포함된 교섭단위를 의미한다. 이는 ‘복수사용자 교섭단위(multi-employer units)’와는 구별되는 개념인바, 복수사용자 교섭단위는 사용자가 사용자협회 또는 공동교섭단을 구성하여 교섭하는 전통적 형태를 의미한다. 반면, 혼합 교섭단위(mixed unit)는 하나의 사용자 사업장에서 일하는 ‘단독 고용 근로자(solely employed)’와 ‘공동고용 근로자(jointly employed)’를 하나의 교섭단위로 묶을 수 있는가의 문제이다. 혼합 교섭단위는 교섭 주체가 ‘복수 사용자’로 확대되는 효과를 가지지만, 출발점은 교섭단위의 결정라는 점에서, 공동사용자 인정 여부와 교차하지만 동일한 것은 아니다. 앞서 살펴본 공동사용자의 인정 기준과 마찬가지로, 이러한 혼합 교섭단위를 구성하기 위하여 관련 사용자 전원의 ‘동의’가 요구되는가에 관한 NLRB의 입장도 꾸준히 변화해 왔다.

먼저, NLRB는 2000년 M.B. Sturgis Steel Co. 사건³⁴⁾에서 사용자의 동의 없이도 단독 고용 근로자와 공동 고용 근로자가 혼합 교섭단위를 허용할 수 있다고 결정했다. 이 결정은 노동조합이 임시직 근로자 등 다양한 고용 형태의 근로자들을 단일 교섭단위에 포함시켜 조직할 수 있는 기반을 제공했다. 그러나, NLRB는 2004년 Oakwood Care Center 사건³⁵⁾에서 Sturgis 판정을 번복하고, 단독 고용 근로자와 공동 고용 근로

34) MB Sturgis, Inc., 331 NLRB 1298 (2000).

자가 혼합 교섭단위를 구성하려면 모든 관련 사용자의 ‘동의’가 필수적이라고 판단하였다. 즉, 이러한 교섭단위는 ‘복수사용자 교섭단위’에 해당하며, 따라서 NLRA § 9(b)의 ‘사용자 단위(employer unit)’ 개념에 부합하지 않는다고 본 것이다.

NLRB는 앞서 살펴본 2015년 *Browning-Ferris* 결정 이후 2016년 *Miller & Anderson, Inc.* 사건³⁶⁾에서 단일 사용자에게 고용된 근로자와 그 사용자가 다른 사용자와 공동으로 고용하는 근로자를 하나의 ‘혼합 교섭단위(mixed bargaining unit)’로 결합할 수 있다고 판시했다. 다만, NLRB는 이 결정에서 혼합 교섭단위를 허용하되 각 공동사용자는 자신이 통제할 권한이 있는 특정 핵심 고용 조건 및 모든 기타 필수 교섭 사항에 관해 서만 교섭해야 하며, 통제 권한이 없는 사항에 대해서는 교섭할 필요가 없다라는 점을 명확히 하였다.

2) 혼합 교섭단위 결정 시 구체적인 교섭방식

NLRA § 8(d)는 선의의 단체교섭의무를 규정하지만, 단체교섭의 구체적인 방식에 대해서는 명확히 명령하고 있지 않다. 따라서, 혼합 교섭단위가 결정된 경우 공동사용자들이 단체교섭에 참여 방식은 다음의 세 가지 형태가 가능하다.

(1) 공동교섭

복수의 공동사용자 모두가 사용자 측 위원으로 참석하여 하나의 테이블에서 노동조합과 교섭하는 방식이다. 이러한 방식은 혼합 교섭단위에서 가장 전형적으로 상정되는 교섭 방식이다.

(2) 사용자 간 위임교섭

복수의 공동사용자가 합의하여 사용자 중 일방 또는 공동사용자들로 구성된 ‘교섭위원회’가 실제 단체교섭을 담당하고, 실제 교섭에 참여하

35) *Oakwood Care Center*, 343 NLRB 659 (2004).

36) *Miller & Anderson*, 364 NLRB No. 39 (2016).

지 않은 공동사용자는 단체교섭의 결에 대한 승인권만 행사하는 방식이다. 다만, 이러한 경우에도 각 공동사용자는 자신이 통제하는 사항, 즉 자신이 교섭의무를 부담하는 사항에 관한 최종적인 책임은 부담한다.

(3) 분리교섭

이는 각각의 복수사용자가 자신이 교섭의무를 부담하는 사항에 관하여 각각 별도의 세션에서 교섭을 진행하는 방식이다. 다만, 혼합 교섭단위는 본질적으로 단일한 교섭단위에 해당하므로, 최종적인 교섭 결과는 상호 모순되지 않고 하나의 체계로 운영되어야 한다. 만일 사용자들이 분리 교섭을 통하여 단체교섭을 지연하거나 무력화하려는 경우에는 NLRA § 8(a)(5) 위반으로 간주될 수 있다.

3. 비교법적 시사점

미국 NLRA상 공동사용자 법리의 최근 10여 년 전개는 ‘누가 사용자에 해당하는가’라는 단일 질문의 정답을 확정하는 과정이라기보다, 사용자성 인정이 가져오는 법률효과가 어떠한 규범형식과 통제구조 속에서 배분되는가를 둘러싼 제도적 경합으로 이해되어야 한다. 공동사용자 판단기준은 코먼로상 통제 개념을 상위 준거로 하되, NLRB의 규칙 제정(rulemaking)과 개별 사건 결정(adjudication)이 교차하는 방식으로 형성되었고, 그 결과 실무상 적용 기준 역시 규칙의 존속 여부, 사법심사 경로, 그리고 ‘통제’ 개념의 외연을 둘러싼 법원의 관여 방식에 따라 반복적으로 변동하였다. 특히 2015년 Browning-Ferris 결정이 ‘간접적 통제’ 및 ‘유보된 통제권’의 고려 가능성을 전면화한 이후, 2020년 규칙이 이를 ‘핵심적 고용조건’에 대한 ‘실질적 직접·즉각적 통제’로 재협소화하였고, 2023년 규칙은 다시 확장 방향으로 회귀하였으나 행정법적(APA) 심사에서 무효로 판단되면서, 결국 현재 실무의 준거는 2020년 규칙으로 고정되는 국면에 이르렀다. 이러한 연혁은 미국조차 공동사용자 판단기준을 ‘안정된 실체 규범’으로 수렴시키는 데 실패했음을 보여준다. 따라서, NLRA상 공동사용자 법리의 비교법적 시사점은 판단의 특정 표지

(간접 통제, 유보 권한 등)의 수입 가능성 자체보다는, 2025년 개정법에 따른 사용자성 확장 이후 법률효과를 어떻게 설계하고 통제할 것인가라는 ‘효과 배분’의 문제에 있다고 할 것이다.

나아가, 공동사용자 범리는 교섭단위 결정 및 교섭구조와도 밀접한 관련이 있다. 공동사용자로 인정된다는 것이 곧바로 복수사용자를 포괄하는 ‘단일한 교섭단위’를 당연히 구성하는 것이 아니라, ① 대표선거를 위한 교섭단위 설정 단계에서 어떤 사용자들을 교섭 구조 안으로 포함시킬 것인지, ② 포함된 사용자들 사이에서 단체교섭의 상대방 지위를 어떻게 배치할 것인지, ③ 그 결과로 발생하는 교섭의무 및 책임(특히 성실 교섭의무·정보제공의무·부당노동행위 책임)의 귀속 범위를 어떠한 기준으로 제한할 것인지에 관한 선택의 문제가 발생한다. 따라서, 공동사용자 범리는 ‘사용자성’의 문턱을 어디에 둘 것인가의 문제인 동시에, 그 문턱을 넘은 이후 법률효과를 교섭단위·교섭대상·책임 귀속의 층위에서 조정하는 문제로 전환된다. 미국법의 이러한 경험은 사용자성 판단을 과도하게 단선화할 경우 교섭 구조의 실효성과 책임의 정합성이 훼손될 수 있음을 보여주며, 반대로 사용자성 확장 자체를 비교적 넓게 인정하더라도 법률효과 단계에서 규범목적과 관여 정도에 비례하여 교섭의무의 범위를 한정하는 ‘단계적(tiered) 설계’가 충분히 가능함을 시사한다.

다음 장에서는 이러한 문제의식을 전제로 2025년 개정 노동조합법 제2조 제2호 후단에 따른 사용자성 확장을 ‘사용자 개념 단계의 분절’이 아니라 ‘법률효과 단계의 제한’으로 이해하는 해석 모델을 모색한다.

III. 사용자성과 단체교섭의무의 단계적 해석 모델

1. 해석의 기본 방향

노동조합법상 사용자성에 관한 논의는 대체로 사용자성의 인정이 사실상 ‘교섭의무 전면 귀속’과 결합되어 논의되는 경향이 있었다. 물론, 하나의 근로자에 하나의 사용자를 상정하는 ‘일원적 사용자’ 모델에서는

이러한 단선적 해석 모델은 불가피한 측면이 있다고 생각된다. 그러나 2025년 개정법은 하나의 근로자에게 복수의 노동조합법상 사용자의 존재를 입법적으로 수용하고 있다는 점에서, 2025년 개정법의 해석에 관한 문제 상황은 ‘사용자성’ 자체 보다는 사용자성의 확장을 통해 사용자로 인정된 ‘제3자’에게 어떠한 법적 의무와 책임을 인정할 것인가에 있다고 생각한다. 그러한 ‘제3자’의 사용자성이 인정된다고 해서 그러한 ‘제3자’에게 곧바로 모든 단체교섭의무, 모든 부당노동행위 책임, 더 나아가 형사책임까지 일괄적으로 귀속되는 구조는 규범목적과 책임원리 측면에서 과도하다. 필자는 2025년 개정법 제2조 제2호 후단 중 “그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라는 문구가 이러한 해석을 뒷받침한다고 생각한다. 즉, ‘노동조합법상’ 단체교섭 의무와 부당노동행위 제도는 모두 종국적으로는 ‘근로조건’과 관련된 규범이므로, 제3자가 ‘근로조건에 대한 실질적·구체적 지배·결정이 미치는 범위’에 한정하여 이러한 의무와 책임을 부과하는 것이 관련 규범의 목적과 비례성에 부합할 것이다. 나아가, 부당노동행위에 관한 형사책임은 특히 명확성의 원칙과 책임주의 원칙의 지배 아래 있다는 점에서 구성요건 해당성 및 책임귀속을 ‘근로조건에 대한 실질적·구체적 지배·결정이 미치는 범위’로 제한하는 해석이 강하게 요청된다.

한편, 이러한 “그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라는 문구를 해석하는 다른 방법으로 이러한 사용자를 ‘부분적 사용자’로 개념화하는 해석론도 가능할 것이다. 법문상 “그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라는 문구의 반대해석상, 그 범위 밖에서는 사용자로 보지 않는다는 해석도 가능하기 때문이다. 그러나, 노동조합법상 사용자 개념은 단체교섭, 쟁의행위, 부당노동행위 구제 등 집단적 노사관계 전반에서 권리·의무의 귀속점(歸屬點)을 형성하는 기능적 개념이다. 따라서, 이러한 귀속점으로서의 사용자 지위를 사건별·의제별로 ‘부분적 사용자’라는 형태로 분절할 경우, 노동관계 당사자성, 교섭대표의 확정, 구체절차에서의 당사자 적격이 불안정해질 위험이 크다. 또한, ‘부분적 사용자’라는 개념을 통해 ‘사용자’의 지위 자체를 분절할 경우, 단체교섭 관계 형성의 시작 단계에서 사용자로 인정되는 “범위”가 구체적으로 확정되어야만 한다는

부담을 초래할 것이고, 이는 절차의 지연과 분쟁의 격화를 초래할 가능성이 크다. 따라서, 관련 분쟁의 초기 단계에서의 절차 지연 및 분쟁의 격화를 피하기 위해서는 “근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”라는 요건을 충족하는 자는 노동조합법상 ‘사용자’이며, 따라서 노동조합법 제2조 제5호의 “노동관계 당사자(勞働關係 當事者)”에 해당한다고 해석하는 것이 보다 기능적인 해석론이라고 생각한다.

따라서, 노동조합법상 ‘사용자’ 개념은 ‘사용자이나, 아니나’라는 일도 양단적으로 판단할 대상으로 보고, 2025년 개정법 제2조 제2호 후단의 “그 범위에 있어서는”이라는 문구는 사용자성 자체를 제한하는 것이 아니라 해당 사용자가 노동조합법상 부담하는 법적 의무와 책임의 범위, 즉 ‘법률효과’를 ‘근로조건에 대한 실질적·구체적 지배·결정이 미치는 범위’로 제한하는 취지로 해석하는 것이 보다 체계정합적이라고 생각한다. 나아가, 이러한 해석 모델은 사용자성의 문턱을 낮추되, 법률효과의 단계에서 비례성과 책임주의를 구현하려는 해석 모델로 이해할 수 있다. 또한, 비교법적으로도 NLRA상 공동사용자 논의 역시 결국 ‘누구에게 단체교섭의무와 부당노동행위 책임을 귀속시킬 것인가’라는 귀속점 설정 문제라는 점과도 조응하는 해석이라고 생각한다.

이러한 기본 방향에 따라 2025년 개정법을 해석할 경우, 구체적으로 문제가 되는 해석상 쟁점은 ① 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따른 사용자의 판단 기준(이하 편의상 “실질적 사용자”라고 칭한다), ② 실질적 사용자가 부담하는 교섭의무의 대상·범위·방식, ③ 실질적 사용자에게 부당노동행위 책임을 귀속시킬 수 있는 범위일 것이고, 위 ③은 다시 부당노동행위 구제절차에서의 (공법상) 책임 귀속 범위와 노동조합법 위반죄(부당노동행위)에서의 형사책임의 귀속 범위로 나누어 볼 수 있을 것이다. 다만, ‘③ 실질적 사용자에게 부당노동행위 책임을 귀속시킬 수 있는 범위’ 부분은 후속연구의 과제로 남기고 아래에서는 ‘② 실질적 사용자가 부담하는 교섭의무의 대상·범위·방식’에 관한 필자 나름의 해석론을 제시하고자 한다.

2. 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따른 ‘사용자성’의 판단 기준

2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따른 ‘사용자성’의 판단은 기본적으로 “(근로계약 체결 당사자가 아니더라도) 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 …… 사용자로 본다.”라는 법문에서 출발해야 할 것이다. 이 규정은 종래 사용자 개념을 근로계약의 형식적 당사자로 한정하여 해석하던 태도를 수정하여, 근로조건에 대한 실질적 지배·결정권의 소재를 기준으로 사용자성을 재구성하려는 입법적 의사를 명시적으로 드러낸 조항으로 이해된다.

한편, 위 법문을 자연스럽게 독해할 경우, 특정 근로자와의 관계에서 근로계약을 체결하지 않는 ‘제3자’가 해당 근로자의 근로조건에 ‘실질적이고 구체적으로 지배·결정’할 수 있는 ‘지위’에 있는 경우, 그러한 ‘제3자’는 해당 근로자와의 관계에서 노동조합법상 사용자로 인정된다는 취지로 이해된다. 여기서 중요한 점은, 노동조합법상 사용자성 판단의 중심이 근로계약의 체결 여부라는 ‘법형식’이 아니라, 관련 근로자의 근로조건에 대한 지배·결정의 ‘현실적 작동 양상’으로 이동하고 있다는 점이다.

한편, 위 규정 중 ‘실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위’라는 문구에서, ‘실질적이고 구체적으로’라는 표현은 근로계약을 체결하지 않은 제3자가 사용자로 인정되기 위해서는 관련 근로자의 근로조건에 단순한 경제적 영향력을 행사하는 것을 넘어 해당 근로자의 근로조건에 대한 ‘현실적 통제 가능성’이 인정될 것을 요구하는 취지로 해석해야 할 것이다. 이는 사용자성을 기계적으로 확장하려는 것이 아니라, 분절된 고용구조 하에서 형식적 사용자와 실질적 결정주체가 괴리되는 경우에 한정하여, 그 괴리를 교정하려는 규범적 장치로 평가할 수 있다.

한편, 위 규정 중 ‘지위’라는 표현은 해당 ‘제3자’가 지배·결정을 실제로 행할 것을 요구하는 취지가 아니라, 이를 행할 수 있는 ‘지위’에 있는 경우에도 사용자로 인정될 수 있다고 이해된다. 다만, 위 규정은 ‘지위’에 ‘실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는’이라는 제한을 두고 있으므로, 유보된 권한은 사용자성 판단의 하나의 단서일 뿐, 그 자체로 곧바로 사용자성이 충족되는 것은 아니다. 이러한 해석은 이는 미국 공동

사용자 논의에서 ‘유보된 권한(reserved authority)’과도 맥락을 같이 한다.

3. 실질적 사용자가 부담하는 교섭의무의 대상·범위·방식

1) 교섭단위의 결정 문제

단체교섭에 관한 ‘교섭단위(bargaining unit)’라는 관념(idea)은 미국 NLRA에서 연원한다. NLRA의 입법 목적은 노사 간의 전쟁(warfare)이 아닌 노사관계의 안정(stability)이며, 단체교섭은 이러한 목표를 달성하기 위한 수단이다. 여기서 단체교섭은 사용자와 노동조합의 상반된 이해관계를 조정하는 것을 목표로 한다. 그러나 단체교섭에 임하는 노사 양측의 이해관계는 복잡하며, 양측 모두 ‘내부적’으로도 상충하는 목표를 가지고 있다. 그런데, 사용자 측 당사자인 기업은 그 경영자가 특정한 교섭 전략을 추구하도록 결정할 수 있는 위계적(hierarchical) 조직이므로, 사용자 내부의 이해상충의 조정은 어렵지 않다. 그러나, 노동조합의 경우 그 내부의 이해상충의 조정이 사용자 기업에 비하여 용이하지 않다. 노동조합은 기본적으로 민주적(democratic) 조직이며, 노동조합을 대표하는 대표자는 조합원의 의사에 정치적으로 기속되기 때문이다. 따라서 단체교섭은 노동조합이 내부 갈등을 조율하지 못할 경우, 단체교섭이 혼란스러워질 가능성이 있다. 반대로, 노동조합 측의 내부 갈등이 적을수록 단체교섭이 성공할 가능성이 커진다. 한편, NLRA는 개별 근로자의 이해관계는 그들의 직무(job)에 따라 상당 부분 결정된다고 가정한다. 따라서, 노동조합이 대표하는 근로자의 직무가 유사할수록 노동조합 측의 내부 갈등이 줄어들고, 따라서 단체교섭이 성공할 가능성이 커진다고 이해한다. 그 결과, NLRB는 직무 유사성을 포함하여, 감독·임금체계·기술·근로조건·교류 등 여러 요소를 종합하여 ‘이해관계의 공통성(community of interest)’을 판단한다. 이처럼 NLRA의 ‘교섭단위’는 기본적으로 다양한 이해관계를 가진 근로자 집단을 이해관계의 공통성(community of interest)을 기준으로 묶어서 단체교섭의 효율성을 제고하고, 궁극적으로 단체교섭을 통한 산업평화에 기여할 수 있는가라는 관점에서 파악된다. 즉, NLRA에서 교섭단위는 근로자의 교섭대표 선택을 제도화하는 동시

에, 유효한 단체교섭을 가능하게 하여 산업관계의 안정에 기여하도록 설계된 제도적 장치로 이해된다.

반면, 우리나라의 경우 교섭창구 단일화 제도가 노동조합법에 도입된 경위를 살펴보면 그 출발이 미국과는 다소 상이하다. 먼저, 1997. 3. 13. 법률 제5310호로 제정된 「노동조합 및 노동관계조정법」(이하 “노동조합법”이라고 함) 부칙 제5조는 다음과 같은 내용을 담고 있었다.

「제5조 (노동조합 설립에 관한 경과조치) ① 하나의 사업 또는 사업장에 노동조합이 조직되어 있는 경우에는 제5조의 규정에 불구하고 2001년 12월 31일까지는 그 노동조합과 조직대상을 같이 하는 새로운 노동조합을 설립할 수 없다.

② 노동부장관은 설립하고자 하는 노동조합이 제1항의 규정에 위반한 경우에는 그 설립신고서를 반려하여야 한다.

③ 노동부장관은 2001년 12월 31일까지 제1항의 기한이 경과된 후에 적용될 교섭창구 단일화를 위한 단체교섭의 방법·절차 기타 필요한 사항을 강구하여야 한다.」 (밑줄은 필자)

위 부칙은 1997년 노동조합법의 신규제정으로 상급단체의 복수노조는 즉시 허용하되, 단위사업장의 복수노조는 2002년부터 허용하기로 유예하고, 단위사업장의 복수노조 허용의 전제로 ‘교섭창구의 일원화 등 단체교섭의 방법·절차’를 2001년말까지 강구하도록 노동부장관에게 명령한다는 취지이다. 이러한 부칙(附則)은 노동조합법의 본칙(本則)은 아니지만 법률의 내용이므로 규범력을 갖는다. 따라서, 교섭창구 단일화 문제의 근원(根源)은 1997년 제정 노동조합법이다. 다만, 사업장 단위 복수노조 허용의 시행시기는 후속되는 부칙 개정으로 반복하여 연장되었고, 그 과정에서 교섭창구 단일화 요청도 ‘유예의 전제조건’으로 장기간 계류되었다. 결국 단위사업장의 복수노조 허용은 당초 1997년 제정법의 부칙에서 정한 2002년이 훌쩍 지난 2010년 노동조합법 개정을 통해서야 이루어졌고, 동 개정을 통하여 교섭창구 단일화 제도가 도입되었다.

2010. 1. 1. 법률 제9930호로 일부개정된 노동조합법의 개정이유는 다음과 같이 쓰고 있다.

「1997년 「노동조합 및 노동관계조정법」 제정 시 사업 또는 사업장 단위에서 노동조합의 설립의 자유를 보장하고 사용자가 노동조합 전임자에 대한 급여를 지급하는 것을 금지하는 내용을 규정하여 2002년 1월 1일부터 시행하기로 한 후 「노동조합 및 노동관계조정법」을 2차례 더 개정(2001. 3. 28, 2006. 12. 30)하여 시행시기를 다시 정함에 따라 2010년 1월 1일부터 관련 제도가 시행될 예정임. 그러나, 일법적인 보완 없이 2010년 1월 1일부터 시행될 경우 사업 또는 사업장 단위에서 근로조건 통일을 위한 교섭창구 단일화 절차에 대한 효력이 문제되고, 노동조합 전임자에 대한 급여지원을 금지함에 따라 중소기업 노동조합의 활동이 위축될 우려가 있다는 지적이 있었음. 이에 사업 또는 사업장 단위의 노동조합 설립 규제를 철폐하면서 교섭창구를 단일화하도록 하여 근로조건의 통일성 확보 및 교섭이 효율적으로 이루어질 수 있도록 하고, 노동조합의 전임자 급여의 사용자 지급 금지 원칙 하에 예외적으로 임금의 손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등과 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있도록 함으로써 합리적인 노사관계가 산업현장에 정착되도록 하려는 것임.」(밑줄은 필자)

이러한 입법연혁으로부터 다음의 사실을 확인할 수 있다. 먼저, 교섭창구 단일화 제도는 헌법의 요청으로 만들어진 것이 아니라, 1997년 노동조합법을 신규제정할 당시 동법의 부칙 규정에 따라 사업장 단위 복수노조 허용의 전제로 요구된 것이다. 한편, 2010년 개정 노동조합법은 사업장 단위 복수노조 설립 규제를 철폐하면서 교섭창구를 단일화하도록 하여 ‘근로조건의 통일성 확보’ 및 ‘교섭의 효율성’을 위하여 교섭창구 단일화 제도를 도입하였다. 따라서, 현행 교섭창구 단일화 제도는 2010년 노동조합법 개정 이전에 금지되던 ‘사업장 단위’ 복수노조의 해금(解禁)의 대상(對償)으로 도입된 것이다. 따라서, NLRA의 교섭단위는 근로자의 직무 유사성과 이익 공동체를 기준으로 구성 단위를 정의하는 것이지만, 우리나라의 교섭창구 단일화 제도는 ‘근로조건 통일성’과 ‘효율적 교섭’을 위해 ‘단일 교섭대표’를 선출하는 절차적 장치라는 점에서 기능은 유사하지만 법적 구조가 상이하다. 나아가, NLRA의 경우 적절

한 교섭단위에서의 선거(election)을 통해 단체교섭 의무가 비로소 성립하지만, 우리나라의 경우 사용자는 노동조합법 제30조 제1항에 따라 법률에 의하여 직접 성실교섭의무를 부담하므로, 단체교섭의무는 교섭창구 단일화에 의해 비로소 성립하는 것이 아니라는 점에서도 큰 차이가 있다.

한편, 앞서 살펴본 교섭창구 단일화 도입의 입법 연혁은 현행 교섭창구 단일화 제도가 “직접고용 - 단일사용자 - 단일 교섭구조”라는 단선적 해석모델에 기반하고 있음을 보여준다. 따라서, 2025년 개정법으로 하나의 근로자에 복수의 사용자가 존재할 수 있음이 입법적으로 수용된 상황은 기존의 교섭창구 단일화 제도와 체계 내적인 갈등을 유발한다. 따라서, 하나의 근로자에 복수의 사용자가 존재하는 경우의 교섭단위 문제는 기존 노동조합법의 해석으로 해결할 수 있는 범위에서는 기본 노동조합법의 절차를 따르되, 기존 노동조합법이 애초에 상정하지 않는 상황에 대해서는 어떠한 방식으로 교섭단위를 설정하는 것이 ‘단체교섭의 효율성을 제고하고, 궁극적으로 단체교섭을 통한 산업평화에 기여할 수 있는가?’라는 ‘적절한 교섭단위’의 본래의 취지로 돌아가 제도를 설계할 필요가 있다고 생각한다. 이러한 관점에서 2025년 개정법에 따라 하나의 근로자에 복수의 사용자가 존재하는 경우 상정할 수 있는 교섭구조는 다음과 같은 3가지 경우로 유형화하는 것이 기능적일 것으로 생각한다.

(1) 기존 제도를 그대로 적용할 수 있는 사안

특정 노동조합이 소속 조합원과 ‘근로계약을 체결한 사용자’와의 관계에서 단체교섭권을 확보한 경우(즉, 교섭창구 단일화를 통해 배타적 교섭권을 획득했거나, 해당 사업장의 유일노조인 경우)에는 ‘추가적인 요건이나 절차 없이’ 해당 조합원과의 관계에서 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따라 사용자로 인정된 ‘제3자’를 상대로도 단체교섭을 요구할 수 있다고 해석할 필요가 있다. 이는 현행 노동조합법 제29조의2 제1항의 ‘하나의 사업 또는 사업장’은 그 입법 연혁상 관련 근로자들과 근로계약을 체결한 형식적 사용자의 사업 또는 사업장을 의미하는 것으로 이해되며, 나아가 교섭단위 내 선거를 통하여 비로소 사용자의 교섭의무

가 성립하는 NLRA와 달리, 우리나라의 경우 사용자라는 지위 자체에서 성실교섭의무를 근거 지을 수 있음을 고려할 때, 형식적 사용자 단위에서 교섭권을 획득한 노동조합이 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따라 해당 노동조합 소속 근로자와의 관계에서 사용자의 지위에 있는 ‘제3자’에게 단체교섭을 요구할 수 있다고 해석하는 것은 현행법의 해석으로도 가능하기 때문이다.

다만, 이러한 해석이 실질적 사용자에게 기계적으로 무제한적인 교섭의무를 부과하는 것으로 이해되어서는 안 된다. 실질적 사용자는 ① 자신이 ‘근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위’에 있지 않다고 다투거나(사용자 지위 자체의 부정), ② 노동조합이 요구하는 교섭사항에 관하여 지배·결정할 수 있는 지위에 있지 않다고 항변(단체교섭의무의 범위에 관한 항변)하는 방식으로 대응할 수 있을 것이다. 따라서, 관련 쟁송이 제기될 경우 노동위원회나 법원은 이러한 다툼을 전제로 먼저 해당 제3자가 사용자의 지위에 있는가를 판단하고, 다음으로 교섭의제별로 실질적 사용자가 해당 교섭의제에 관한 교섭의무를 부담하는지를 판단하게 된다.

실무상으로는 이러한 쟁송과정에서 증명책임을 어떻게 분배하여야 하는지가 문제될 것이다. 사건으로는 근로계약을 체결하지 않은 제3자가 2025년 개정법 제2조 제2호 후단의 사용자에 해당한다는 점은 이를 주장하는 노동조합 측이 증명하도록 하고, 반면 노동조합이 요구하는 교섭사항에 관하여 지배·결정할 수 있는 지위에 있지 않다고 항변에 대해서는 실질적 사용자에게 증명책임을 귀속시키는 것이 합리적이라고 생각한다. 이는 노동조합 측에서는 외부에서도 파악이 가능한 제3자의 ‘지배력의 외관’을 증명함으로써 해당 제3자에 단체교섭 요구를 할 수 있도록 하고, 반면 관련 근로자에 대한 지배력의 ‘범위’를 명확히 알고 있는 ‘실질적 사용자’는 그러한 지배력의 ‘범위’에 근거하여 교섭의제별로 교섭의무 없음의 항변을 할 수 있도록 하는 구상이다. 실질적 사용자가 내부적인 경영 자료나 도급 계약의 세부 내용을 독점하고 있는 현실을 고려할 때, 노동조합에 완벽한 지배력 범위를 증명하게 하는 것은 실질적 사용자에게 대한 단체교섭권의 행사를 사실상 봉쇄하는 결과를 초래할 수

있음을 고려할 때, 이러한 증명책임의 분배는 정보의 비대칭성이라는 실태를 반영한다는 점에서 공평의 원칙에 부합할 것으로 생각된다. 또한, 이러한 항변 구조는 교섭의제별 책임 귀속이라는 관점에서도 이해될 수 있을 것이다.

(2) 기존 제도의 유추(類推)를 고려할 수 있는 사안

전술한 바와 같이, 기존의 교섭창구 단일화 제도는 ‘하나의’ 사용자 내에 그 근로자를 조직대상으로 하는 복수의 노동조합이 존재할 경우를 상정한 제도이다. 따라서, ① 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 의한 사용자를 기준으로 ② 해당 사용자가 자신과 근로계약을 체결하지 않은 근로자의 근로조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 범위가 기능적으로 하나의 ‘사업’으로 평가될 수 있을 정도로 광범위하고(이러한 경우는 NLRA상 공동사용자보다는 단일 사용자(single employer)에 가까울 것이다), 또한 ③ 해당 사용자와 직접 근로계약을 체결한 근로자와 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따라 해당 사용자의 근로자로 인정되는 자를 포함하는 근로자 집단을 조직대상으로 하는 복수의 노동조합이 존재하는 경우에는 해당 사용자를 기준으로 현행 교섭창구 단일화 제도를 유추를 고려할 수 있을 것이다. 다만, 이러한 유추적용에 있어 교섭단위 전체 근로자의 선거를 통하여 배타적 교섭권을 부여하는 NLRA와 달리 교섭창구 단일화에 참여한 노동조합의 조합원을 기준으로 과반수 노동조합에게 배타적 교섭권을 부여하는 노동조합법 제29조의2 제4항을 그대로 적용할 경우, 실질적 사용자의 사업의 일부 업무를 수행하는 수급인 소속 근로자를 주된 조합원으로 하는 노동조합의 경우 현실적으로 교섭권을 행사할 가능성이 희박해 진다는 문제가 생긴다.

이와 같이 2025년 개정법 국면에서 당초 교섭창구 단일화 제도가 예정하지 않았던 ‘복수 사용자(형식적 사용자와 실질적 사용자)의 병존’이 제도 내부로 유입되면서, 기존 체계의 기계적 적용은 대표성의 왜곡 문제를 발생시킨다. 이러한 상황을 해결하기 위해 고려할 수 있는 해석론으로는 (i) 실질적 사용자의 사업이 하나의 사업으로 인정됨을 전제로, 해당 사업의 일부 근로자를 교섭단위로 하는 교섭단위의 분리를 인정하

는 방안(노동조합법 제29조의3 제1항)과 (ii) 이러한 경우 과반수 조합에게 배타적 교섭권을 부여하는 취지의 제29조의2 제4항의 적용을 배제하고, 같은 조 제5항에 따라 ‘공동교섭대표단’을 구성하여 교섭하도록 하는 방안을 상정할 수 있을 것이다. 그런데, 위 (i)의 경우는 사실상 앞에서 설명한 ‘① 기존 제도를 그대로 적용할 수 있는 사안’과 그 범위가 일치할 것이다. 따라서, ‘하나의 사업 또는 사업장’을 원칙적인 교섭단위로 상정하고, 교섭단위의 분리를 엄격하게 허용해 온 기존의 해석론을 고려할 때, 위 ①의 방식으로 해결할 수 있는 사안에 대하여 ‘교섭단위의 분리’라는 별도의 절차를 거치도록 하는 방식은 실익이 없다고 생각한다. 따라서, 이러한 경우 위 (ii)에 따라 과반수 노동조합이 아니라 해당 교섭단위 내 노동조합들의 ‘공동교섭대표단’으로 하여금 교섭권을 행사할 수 있도록 설계할 필요가 있다.

이 글에서 제시하는 ‘공동교섭대표단을 기본형으로 상정’하는 해석은 ① 2025년 개정법이 명문으로 사용자 범위를 확장한 이상 단체교섭권의 실효성을 확보해야 한다는 헌법상 단체교섭권 보장 취지, ② 가입자격이 상이한 노동조합 간에 일괄적인 단일화를 강제할 경우 가입자격이 없는 근로자의 근로조건이 다른 노동조합에 의해 사실상 결정될 수 있다는 대표성 왜곡의 위험, ③ ‘사용자 지위의 확장’이 결과적으로 하청노조 등의 단체교섭을 봉쇄하는 결과를 가져와서는 안된다는 체계정합성의 요청에 의해 정당화되는 목적론적·헌법합치적 해석으로 위치지을 수 있다. 즉, 교섭창구 단일화는 ‘본래 사업장 단위 복수노조 허용의 대가로서 근로조건 통일성과 교섭 효율성을 확보’하기 위한 절차적 장치였지, 분절된 고용구조에서 실질적 결정주체를 교섭에서 배제하기 위한 장치는 아니므로, 2025년 개정법 시행 국면에서는 규정 목적에 비추어 적용범위를 합리적으로 조정하는 해석은 당연한 요청이라고 할 것이다. 물론 ‘공동교섭대표단’ 중심의 절차 설계는 일부 국면에서 법문의 문언적 한계를 넘는 목적론적 축소를 수반하므로 ‘법형성’이라는 비판이 제기될 수 있다. 그러나, 이 글이 제안하는 해석론은 사용자성의 확장을 명한 2025년 개정법 문언과 충돌하지 않으면서도, 대표성의 왜곡을 방지하는 동시에 교섭대표 구조의 불안정과 절차 지연을 최소화하고, 나아가 실질적 사용

자의 구체적인 단체교섭의무를 의제별로 분절하는 ‘법률효과 제한 모델’과 결합하여 실질적 사용자의 부담을 비례적으로 통제한다는 점에서, 헌법합치·체계정합 해석으로 평가될 수 있다고 생각한다.

따라서 2025년 개정법 국면에서는 교섭창구 단일화 규정의 목적론적 축소를 통하여, 공동교섭대표단을 중심으로 한 교섭 구조를 우선적으로 설계하는 것이 단체교섭권 보장의 관점에서 보다 설득력 있다고 생각한다. 다만, 별도의 입법 없이 노동조합법 제29조의2 제4항의 적용을 배제하는 것은 법해석의 차원을 넘는 ‘목적론적 축소’에 의한 법형성에 해당한다. 따라서, 이러한 법형성에 대한 법치주의적 관점에서의 비판 가능성을 고려할 때, 입법을 통하여 명확하게 ‘공동교섭대표단’(29조의2 제5항)을 기본형으로 하고, 근로자 집단의 동질성이 높고 대표성 침해 위험이 낮은 경우에 한하여 과반수 노조의 배타적 대표를 예외적으로 인정하는 방안을 모색하는 것이 바람직할 것이다. 그러므로, 이러한 입법이 있기 전까지는 위 ①의 해석론에 따라 기존 제도를 그대로 적용할 수 있는 사안의 경우에는 별도의 교섭창구 단일화 없이 기존의 교섭절차에 실질적 사용자를 인입(引入)하는 방식으로 대응하는 것이 현실적인 해결책이라고 생각한다.

(3) 명확하게 기존 제도 외부에 있는 사안

필자는 2025년 개정법 상황에서의 ‘교섭창구 단일화’ 및 그 전제로서의 ‘교섭단위’의 합리적인 결정을 위해서는 ‘사업장’의 범위를 어떻게 확정할 것인가의 문제에 앞서 문제가 되는 노동조합들의 ‘조직범위’를 살펴볼 필요가 있다고 생각한다. 현행 교섭창구 단일화 제도는 일원적(unitary) 사용자 개념을 전제로 해당 사용자에게 소속된 근로자들을 조직대상에 포함하는 복수의 노동조합을 전제로 교섭창구의 창구단일화를 요구하는 제도이다. 따라서, 애당초 문제가 되는 노동조합 상호 간에 조직대상이 다를 경우, 개별 근로자 입장에서 자신이 가입할 수도 없는 노동조합에 의하여 자신의 근로조건이 교섭되는 부당한 결과가 발생할 수 있다. 가입 자격이 없는 노동조합에 의해 근로조건이 결정되는 것은 단결권 및 단체교섭권에 대한 본질적인 침해로 평가될 수 있기 때문이다.

따라서, 예컨대 수급인 근로자의 가입을 허용하지 않는 도급인 소속 근로자를 조직대상으로 하는 노동조합(편의상 “원청노조”라고 한다)과 수급인 근로자로 조직된 노동조합(편의상 “하청노조”라고 한다) 사이의 교섭창구 단일화는 애당초 고려의 대상이 될 수 없다고 생각한다. 따라서, 이러한 유형의 경우 문제의 핵심은 ‘교섭창구 단일화’라기 보다, 서로 다른 조직범위를 갖는 복수의 노동조합과 복수의 사용자 간에 어떠한 범위에서 공동의 교섭틀을 형성할 수 있는가라고 생각한다. 전술한 바와 같이, 가입 자격이 없는 노동조합에 의해 근로조건이 결정되는 결과는 단결권 및 단체교섭권의 본질적 침해로 평가될 수 있으므로, 이러한 유형에서는 당사자들의 명시적 동의를 전제로 한 공동교섭의 방식이 정당화될 수 있을 것이다. 이는 미국법상 다수 사용자 교섭단위(multi-employer bargaining unit)가 원칙적으로 사용자 측의 동의를 전제로 형성되는 것과도 기능적으로 유사하다.

2) 교섭의무의 귀속 범위

전항에서 기술한 바와 같이, 2025년 개정법 제2조 제2호 후단에 따라 실질적 사용자성이 긍정된다고 실질적 사용자에게 기계적으로 무제한적인 교섭의무를 부과하는 취지는 아니다. 따라서, 실질적 사용자가 부담하는 구체적인 교섭의무의 범위가 문제될 것인바, 이에 관해서는 “근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라는 문구에서 ① 근로자의 ‘근로조건’과 ② ‘실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위’의 해석이 문제된다.

(1) 근로조건

실질적 사용자가 부담하는 단체교섭 ‘의무’의 구체적인 귀속 범위를 판단하는 맥락에서의 ‘근로조건’은 기본적으로 의무적 교섭대상으로서의 근로조건을 의미하는 것으로 이해할 필요가 있다. 왜냐하면, 2025년 개정법 제2조 제2호 후단의 취지가 실질적 사용자로 하여금 자신과 직접 근로계약을 체결한 근로자와의 관계에서 단체교섭의무를 부담하지

않는 사항(임의적 교섭대상)³⁷⁾에 대해서까지 단체교섭의무를 부담시키는 취지로 해석하기는 어려울 것이기 때문이다.

그런데, NLRA § 8(d)가 의무적 교섭사항을 “임금, 근로시간 및 기타 고용의 여러 조건”(wages, hours, and other terms and conditions of employment)이라고 규정하고 있는 것과 달리 현행 노동조합법은 단체교섭의 대상에 관하여 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 다만, ‘노동쟁의’의 정의에 관한 노동조합법 제2조 제5호에서 “임금·근로시간·복지·해고·근로자의 지위 기타 대우등 근로조건의 결정”이라고 규정하고 있는바, 노동쟁의는 단체교섭을 논리적 전제로 한다는 점에서 적어도 ① 임금, ② 근로시간, ③ 복지, ④ 해고, ⑤ 근로자의 지위 및 ⑥ 기타 대우는 의무적 교섭사항³⁸⁾에 해당하는 근로조건의 핵심적인 영역을 구성하는 것으로 이해할 수 있을 것이다. 이처럼, 현행 노동조합법은 NLRA와 달리 의무적 교섭사항을 명문으로 규정하지 않으므로, 이하에서는 ‘노동쟁의’의 정의 규정을 해석의 출발점으로 삼는다.

(2) 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위

먼저, 근로조건에 대하여 ‘지배·결정할 수 있는 지위’는 그러한 지위의 발생 원천에 따른 유형화가 필요할 것인바, 이러한 지위가 발생할 수 있는 근거로는 ① 근로자와 직접 계약을 체결한 경우, ② 제반 법령에 따라 근로자에 대하여 의무를 부담하는 경우(공법상 의무를 포함함), ③ 계약이나 출자관계에 있는 형식적 사용자를 매개하여 근로조건에 대하여 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 경우로 나누어 볼 수 있을 것이다.

첫째, ① ‘근로자와 직접 계약을 체결한 경우’란 실질적 사용자와 근로자 사이에 어떠한 직접적인 계약관계가 존재하는 경우이다. 계약의 종류는 불문하나, 그러한 계약이 ‘근로계약’에 해당할 경우에는 2025년 개정법 제2조 제2호 후단의 사용자가 아니라 ‘근로계약 체결 당사자’로서의

37) 사용자의 교섭거부가 노조법 제81조 제1항 제3호(단체교섭 거부)의 위법으로 평가되지 않는 교섭사항이라는 의미이다.

38) 사용자의 교섭거부가 노조법 제81조 제1항 제3호(단체교섭 거부)의 위법으로 평가되는 교섭사항이라는 의미이다.

사용자(고용주)가 될 것이므로, 실질적으로는 근로계약 이외의 계약을 체결한 경우가 이에 해당할 것이다. 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는 노동조합법상 근로자(예컨대, 노무제공자)와 근로계약 이외의 노무공급계약을 체결한 사업주가 이에 해당할 것이다. 이러한 경우에는 실질적 사용자는 제3자를 매개하지 않고 직접적으로 자신이 체결한 계약에 근거하여 근로자의 근로조건을 지배·결정할 수 있는 지위에 있다는 점에서 ‘실질적이고 구체적으로’라는 요건의 충족이 용이할 것이다.

둘째, ② ‘제반 법령에 따라 근로자에 대하여 의무를 부담하는 경우’란, 파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 “파견법”) 제34조(근로기준법의 적용에 관한 특례) 및 제35조(산업안전보건법의 적용에 관한 특례)에 따라 사용자업주가 파견근로자에 대하여 근로기준법 및 산업안전보건법상 의무를 부담하거나, 산업안전보건법 제63조에 따라 관계수급인의 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 안전조치 및 보건조치 의무를 부담하는 도급인 등이 이에 해당할 것이다. 한편, 2025년 개정법 제2조 제2호 후단의 ‘지배·결정할 수 있는 지위’가 반드시 실질적 사용자와 관련 근로자 사이의 사법(私法)상 법률관계를 전제로 한 것으로 보기는 어렵다는 점에서, 관련 법령에 따라 실질적 사용자가 부담하는 의무가 공법(公法)상 의무에 해당한다고 하더라도 ‘지배·결정할 수 있는 지위’가 인정될 수 있을 것이다. 다만, 이러한 공법상 의무의 존재만으로 곧바로 모든 근로조건에 관한 단체교섭의무가 발생하는 것은 아니며, 해당 법령이 예정하고 있는 의무의 내용과 범위가 단체교섭을 통해 조정 가능한 근로조건과 실질적으로 연결되는 범위, 즉 해당 법령이 사용자에게 부과한 의무의 구체적 내용이 단체협약을 통해 구체화될 여지가 있으며, 상대방이 그 이행수단을 실질적으로 보유하는 경우에 ‘그 범위에서’ 단체교섭의무가 인정될 것이다.

한편, 이러한 경우에는 실질적 사용자의 권한과 의무의 범위가 법령에 의해 비교적 명확히 특정된다는 점에서, ‘실질적이고 구체적으로’라는 요건의 충족 여부의 판단은 상대적으로 용이할 것이다. 예컨대, 관계수급인의 근로자에 대하여 산업안전보건법상 안전조치 의무를 부담하는 도급인을 상대로 관계수급인의 근로자로 조직된 하청노조가 안전 장비

개선 등에 관한 단체교섭을 요구할 경우, 이러한 교섭사항은 당연히 도급인의 단체교섭의무 범위에 포함될 것이다.

셋째, ③ ‘계약이나 출자관계에 있는 형식적 사용자를 매개하여 근로조건에 대하여 지배·결정할 수 있는 지위’란, 기본적으로 실질적 사용자(제3자)와 근로자 사이에 형식적 근로계약이 존재하지 않는 상황에서, 실질적 사용자(제3자)가 형식적 사용자를 매개하여 근로조건에 대하여 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 경우를 의미한다. 위 ①과 ②의 경우, 계약이나 법령 등 ‘지배·결정할 수 있는 지위’를 근거 지을 수 있는 법적 원천이 비교적 명백한 반면, ③의 경우에는 실질적 사용자는 형식적 사용자와 체결한 계약(예컨대, 사내하도급, 근로자공급계약)이나 출자관계(예컨대, 완전모자회사) 등 다양한 원천에 근거하여 ‘지배·결정할 수 있는 지위’에 설 수 있다. 따라서, ③의 경우에는 단체교섭의무의 구체적인 범위는 ‘실질적이고 구체적으로’라는 요건의 해석에 의존하게 될 것이다. 한편, ‘실질적이고 구체적’으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는가를 판단하는 ‘판단틀’과 관련하여서는, ‘목적론적 접근’과 ‘구조적 접근’을 종합적으로 고려하는 방식이 유용할 것이다.

가) 목적론적 접근

2025년 개정법 제2조 제2호 후단의 목적은 기본적으로 분절된 고용구조 하에서 형식적 사용자와 실질적 결정주체의 괴리(乖離)로 초래된 문제를 해결하는 것이다. 이를 단체교섭의 국면에 적용해 보면, 실질적 사용자에게 어떠한 범위에서 단체교섭의무를 부과할 것인가에 관한 판단의 초점은 ‘실질적 사용자를 배제한 채 형식적 사용자만을 단체교섭의 상대방으로 할 경우 실효적인 단체교섭이 가능한가’의 문제가 되어야 할 것이다. 따라서, 목적론적 접근의 핵심 질문은 관련 교섭사항에 관하여 형식적 사용자가 독자적으로 단체협약을 체결하고, 이를 이행할 수 있는지 여부가 될 것이다. 만약 형식적 사용자가 단체교섭 과정에서 어떠한 근로조건을 변경하거나 양보하기 위해 제3자의 관여가 필요하다면, 제3자는 그러한 근로조건에 관하여 ‘실질적이고 구체적으로’ 지배·결정할 수 있는 지위에 있다고 볼 수 있을 것이다.

나) 구조적 접근

위 ‘목적론적 접근’은 근로자와 직접 근로계약을 체결하지 않은 제3자에게 단체교섭의무를 부과하는 이념적 기초(헌법상 단체교섭권의 실질적 보장)와 맞닿아 있다는 점에서 실질적 사용자의 단체교섭의무의 범위를 확정하는 판단근거로 높은 설명력을 갖는다. 다만, 목적론적 접근은 ‘형식적 사용자 외의 제3의 기업이 단체교섭에서 배제될 경우, 근로자가 자신의 근로조건에 관하여 단체교섭을 할 권리가 실질적으로 저해되는가?’라는 핵심 질문 자체가 다소 추상적인 수준이라는 점에서 실질적 사용자(제3자)와 형식적 사용자 및 그 근로자 사이의 구조적 관계를 직시하여 실질적 사용자의 사실상의 통제력의 실체를 규명하는 방식(필자는 이를 ‘구조적 접근’이라고 부르고자 한다)으로 보충될 필요가 있다.

이러한 구조적 접근은 형식적 계약이라는 ‘외피’ 뒤에 숨은, 현실적 지배력의 ‘구조(structure)’를 실증적으로 규명하는 접근으로 정의할 수 있을 것인바, 이는 계약을 통해 만들어진 관계의 현상 아래에는 그러한 관계를 지배하는 구조가 작동하고 있다는 이해에 기반한다. 따라서, 구조적 접근의 핵심은 구체적인 증거에 기반하여 실질적 사용자와 근로자의 근로조건의 지배·결정 사이의 ‘실질적 연결고리’를 확정하는 작업이며, 구체적으로는 제3자가 형식적 사용자를 매개로 근로조건의 ‘결정구조’ 자체를 지배하고 있는지(구조적 지배)를 실증적으로 규명하는 작업이다. 따라서, 이러한 ‘구조적 지배’는 근로자가 제공하는 노무에 대한 지휘가 아니라, 임금·근로시간·정원 등 근로조건의 결정구조를 누가 지배하는가를 의미한다. 만일, 제3자가 이러한 근로조건의 결정구조 자체를 지배한다면, 결국 관련 근로조건의 결정에 관한 형식적 사용자의 독자적 결정 가능성이 ‘구조적’으로 제한되게 되며, 따라서 이러한 경우 앞의 ‘목적론적 접근’의 관점에서도 제3자(실질적 사용자)에게 단체교섭의무를 부과하는 것이 정당화될 것이다.

(3) 판단기준의 유형화

전술한 바와 같이 실질적 사용자는 형식적 사용자와 체결한 계약(예컨대, 사내하도급, 근로자공급계약)이나 출자관계(예컨대, 완전모자회사)

등 다양한 원천에 근거하여 ‘지배·결정할 수 있는 지위’에 설 수 있다. 아래에서는 ‘목적론적 접근’과 ‘구조적 접근’의 구체적인 적용 방식의 가능한 유형을 몇 가지 예를 들어 제시한다.

가) 완전모자회사 기타 출자관계

완전모자회사 또는 지주회사·사업회사 등의 관계에서 완전모회사 등이 자회사 근로자의 임금의 재원(原資), 임금표, 근로자의 정원, 평가 및 승급(昇給) 기준 등을 일괄적으로 설정·승인하고, 자회사가 사실상 이러한 기준을 이탈하여 근로조건을 변경할 수 없는 경우에는, 자회사 등 형식적 사용자가 단체교섭에 임하더라도 임금·인원·평가와 같은 핵심적인 근로조건에 관하여 교섭과정에서 실질적인 양보나 변경을 하기 위해서는 모회사 등의 승인에 의존할 수밖에 없게 된다. 따라서, 이러한 경우 완전모회사 등은 해당 근로조건의 결정구조를 구조적으로 지배하는 지위에 있다고 보아야 할 것이다.

나) 도급계약 관계

도급계약 관계에서 도급인이 도급단가 산정 과정에서 표준공수(工數)·표준인원·노무비 비중을 설정하고, 추가 인력 투입 및 연장근로 등에 대해 도급인의 사전 승인을 받도록 하는 등 수급인의 인건비 배분과 근로시간 운영을 구조적으로 제약하는 경우에도 구조적 지배가 인정될 수 있을 것이다. 이러한 구조에서는 수급인이 형식적 사용자로서 단체교섭을 통해 임금이나 근로시간을 조정하려 하더라도, 도급단가 및 기성금 정산 구조 자체가 변경되지 않는 한 실질적인 개선이 불가능해지므로, 도급인은 해당 근로조건에 관하여 ‘실질적이고 구체적으로’ 지배·결정할 수 있는 지위에 있다고 평가할 수 있을 것이다.

참고로, 근로조건에 관한 이러한 구조적 지배와 불법파견 판단에 있어서의 핵심지표인 업무상의 지휘·명령이나 실질적 편입(編入)은, 전자의 경우 ‘근로조건의 결정’ 자체에 관한 구조적 지배에 착목한 판단인 반면 후자의 경우 수급인의 근로자가 도급인의 사업에 편입되어 그 노무지휘권에 복종하는가에 관한 평가라는 점에서 서로 그 목적이 다르다. 따라

서, 도급계약이 불법파견에 이르지 않는 경우에도 근로조건에 관한 구조적 지배는 당연히 긍정될 수 있다. 따라서, 도급인이 하청노조의 단체교섭에 응하는 순간 불법파견을 자인하게된다는 일부 주장은 법리적으로 수용하기 어려운 측면이 있다. 한편, 일각에서 사용되는 ‘구조적 통제’라는 표현은 불법파견의 판단기준과 구조적 지배의 판단기준이 동일한 것이라는 오해를 야기할 수 있다고 생각한다.

다) 근로자공급

근로자공급의 경우, 수요업체가 임용, 배치 인원, 근무표, 업무량, 현장평가 및 교체 요구 권한을 장악하여, 공급업체가 사실상 이를 전달·집행하는 역할에 그치는 경우, 근로조건의 핵심 요소가 수요기업의 결정에 종속되는 구조가 형성된다. 다만, 노동조합에 대해서만 근로자공급 사업을 허용하는 우리나라의 상황에서, 공급근로자와 수요기업 사이의 단체교섭을 어떻게 설계할 것인가의 문제가 남는다.

우리나라의 경우, 노동조합은 직업안정법에 따라 근로자공급사업을 영위함과 동시에, 조합원의 노동조건을 보호하는 노동조합으로서 이중적 지위를 갖는다. 이러한 독특함은 노동법 체계 내에서 사용자성, 근로자성, 단체교섭 구조와 같은 쟁점과 관련하여 실질과 법형식의 괴리 문제를 드러내고 있다. 하지만, 오랫동안 이러한 법률관계에 관한 법원의 해석은 법적 혼란 상태에 놓여 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 무엇보다 항운노조 조합원의 법률관계를 모순 없이 정합적으로 재구성할 필요가 있다. 사건으로는, 항운노조와 수요기업 사이의 공급계약을 ‘집단적 근로계약’으로 관념할 경우, 항운노조는 ① 노동조합과 ② 노동그룹(Arbeitsgruppe)이라는 두 가지 지위를 동시에 갖는 것으로 볼 수 있을 것이다. 이렇게 이해할 경우, 노동조합이 노동조합의 지위에서 소속 조합원의 근로조건 등에 관하여 수요기업과 체결하는 ‘단체협약’과 노동조합이 조합원 중 특정 수요기업의 업무를 수행할 일부 근로자집단(노동그룹)을 대표하는 업무집행자로서 체결하는 ‘집단계약’으로서의 근로자공급계약을 관념적으로 구별할 수 있을 것이고, 따라서 수요기업을 실질적 사용자로 보아 단체교섭의무를 부과하는 것도 가능할 것이다.³⁹⁾

라) 프랜차이즈 관계

프랜차이즈 관계에서도, 가맹본부가 가맹점의 영업시간, 필수 인력 기준, 요금·수수료 체계를 통해 가맹점의 인력운영과 근로시간·소득 형성을 구조적으로 규율하는 경우에는, 가맹본부는 형식적 사용자(가맹점)와 근로자 사이의 근로조건 결정구조를 사실상 지배한다고 평가될 수 있을 것이다. 이러한 경우 형식적 사용자(가맹점주)만을 단체교섭의 상대방으로 한정할 경우, 근로조건의 실질적 결정주체가 단체교섭에서 배제되어 단체교섭권의 실효적 행사가 저해될 위험이 발생한다면, 가맹본부를 실질적 사용자로 보아 단체교섭의무를 부과하는 것도 가능할 것이다.⁴⁰⁾

IV. 결론

2025년 개정 노동조합법 제2조 제2호 후단의 ‘그 범위에 있어서는 사용자로 본다’는 문언은, 표면적으로는 제3자의 사용자지위를 의제별로 쪼개는 이른바 ‘부분적 사용자론’을 유인할 수 있다. 그러나 노동조합법상 ‘사용자’는 단체교섭·쟁의행위·부당노동행위 구제 등 집단적 노사관계 전반에서 권리·의무의 귀속점을 형성하는 기능적 개념이므로, 사용자 지위 자체를 사건·의제별로 분절하는 해석은 교섭 개시 단계에서부터

39) 최근 중앙노동위원회 2025. 5. 30. 2024부노204 재심판정에서 “노동조합법 및 직업안정법의 입법 취지, 근로자공급사업의 특수성 및 당사자 사이의 노무제공 관계의 실질을 고려하여 보면, 도매시장법인은 하역 노무자 노동조합 조합원들의 임금과 작업환경 등에 관하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자로서 노동조합법상 하역 노무자 노동조합에 대하여 단체교섭 의무 및 부당노동행위 책임 등을 부담하는 사용자에게 해당한다.”고 실시하고, 이에 근거하여 하역 노동조합의 단체교섭 요구에 응하지 않은 행위를 단체교섭 거부로 부당노동행위로 판단한바 있다.

40) 프랜차이즈 계약에서 영업시간·가격·필수 인력기준 등이 본부에 의해 구조적으로 설정되는 경우, 가맹점주의 독자적 근로조건 결정 가능성은 실질적으로 제한된다는 점에 관한 선행연구로는 강성태, “프랜차이즈 관계와 노동법의 적용 - 미국법의 최근 동향을 중심으로 -”, 『노동법학』 제70호, 2019 참조.

‘사용자성 범위 확정’을 선행요건으로 만들어 절차 지연과 당사자적격 혼란을 구조적으로 증폭시킬 위험이 크다. 따라서 위 문언은 사용자성 성립범위를 축소하는 규정이라기보다, 사용자로 인정된 제3자에게 귀속되는 구체적 법률효과(단체교섭의무 및 부당노동행위 책임)의 범위를 ‘근로조건에 대한 실질적·구체적 지배·결정 가능성’이 미치는 의제별 범위로 제한하는 기능을 수행하는 것으로 해석함이 체계정합적이다. 이와 같이 이해할 때, (1) 사용자성 단계에서는 문턱을 상대적으로 낮추어 분절된 고용구조에서 단체교섭권의 실효성을 확보하되, (2) 교섭의무 단계에서는 지배·결정 가능성이 인정되는 의제에 한정하여 부담을 분절하고, (3) 책임 단계(특히 형사책임)에서는 명확성원칙·책임주의·비례성에 따라 귀속가능성을 한층 엄격하게 요구하는 단계적(tiered) 효과 제한 모델이 성립한다.

위와 같은 해석구성은 미국법의 특정 기준을 ‘기계적으로 수입’하기 위한 것이 아니라, 분절된 고용구조에서 사용자성 확장이 가져오는 법률효과를 ‘교섭의무’와 ‘책임’으로 분해하여 재배치하는 규범 설계의 관점에서 비교법적 시사점을 얻기 위한 것이다. 특히 미국에서도 공동사용자 판단기준은 코먼로의 준거, NLRB의 규칙 제정, 개별 결정, 그리고 연방법원의 사법심사라는 상이한 형식과 위계의 교차 속에서 형성되어 왔고, 그 결과 실체 기준이 정치적·제도적 진자운동을 반복해 왔다. 이 점은 한국이 특정 실체 기준의 채택 여부에 논의를 수렴시키기보다, 사용자성 확장 이후의 법률효과를 단계적으로 배분하는 ‘효과 설계’에 초점을 맞추어야 한다는 결론을 뒷받침한다.

마지막으로, ‘분절된 고용구조에서의 단체교섭 체계’는 해석론만으로는 완전하게 해결하기 어렵다고 생각한다. 먼저, 기존의 교섭창구 단일화 제도는 본래 ‘단일 사용자’를 전제로 하고 있어, 복수의 사용자를 포괄하는 교섭단위에서 배타적 교섭대표 방식을 일률적으로 관철할 경우 노동조합의 대표성 왜곡이나 단체교섭의 봉쇄 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 향후 공동교섭대표단 중심으로 교섭창구 단일화 절차를 재설계하는 방안의 검토가 필요하다. 또한, 구조적인 정보비대칭이 존재하는 간접고용 관계에서 교섭의무의 실효성을 확보하려면, 사용자성의 판단

및 구체적인 교섭의무의 범위에 관한 증명책임의 배분 및 증거자료의 제출을 촉진하는 절차적 장치가 강화되어야 할 것이다.

주제어: 균열 일터, 공동사용자 법리, 단체교섭 의무, 사용자 지위 확대,
법률 효과의 단계적 배분

참고문헌

- 강성태, “프랜차이즈 관계와 노동법의 적용 - 미국법의 최근 동향을 중심으로 -”, 『노동법학』 제70호, 2019.
- 강주리, “미국 연방노동관계법상 공동사용자 지위 결정에 관한 규칙 개정의 의미 - 초기업별 교섭에서 사용자 지위 및 교섭의무 판단을 둘러싼 쟁점을 중심으로 -”, 『산업관계연구』 제34권 제2호, 2024.
- 김미영, “사내도급 고용관계에서 부당노동행위 책임 - 미국 공동사용자 원리와 비교 -”, 『노동법포럼』 제21호, 2017.
- 이태현, “미국 공동사용자 법리의 현황과 시사점 - 브라우닝 펠리스 결정과 그 이후의 전개를 중심으로 -”, 『노동법학』 제86호, 2023.
- Carvell, Steven A. & Sherwyn, David, “It Is Time for Something New: A 21st Century Joint-Employer Doctrine for 21st Century Franchising”, *American University Business Law Review* 5(1), 2015, 5-36.
- Gould IV, William B., *A Primer on American Labor Law*, 6th ed., Harvard University Press, 2019.
- Green, Michael Z. & Leslie, Douglas L., *Labor Law in a Nutshell*, 6th ed., West Academic Publishing, 2022.
- Hirsch, Jeffrey M., “Joint Employment in the United States”, *Italian Labour Law e-Journal* 13(1), 2020, 55-69.
- Hirsch, Jeffrey M., “Twenty-First Century Employers”, in Richard Bales & Charlotte Garden (eds.), *The Cambridge Handbook of U.S. Labor Law for the Twenty-First Century*, Cambridge University Press, 2019, 128-139.
- Shimabukuro, Jon O., *Joint Employment and the National Labor Relations Act*, Congressional Research Service, Report No. R47943, Sept. 10, 2024.
- Pasternak, Daniel B. & Perera, Naomi Y., “The NLRB’s Evolving Joint-Employer Standard”, *ABA Journal of Labor & Employment Law* 31(2), 2016, 295-324.
- Ray, Douglas E., Strassfeld, Robert N. & Levinson, Ariana R., *Understanding Labor Law*, 5th ed., Carolina Academic Press, 2019.
- Slater, Joseph, “Some Problems With NLRA Coverage: Independent Contractors

and Joint Employers”, in Richard Bales & Charlotte Garden (eds.), *The Cambridge Handbook of U.S. Labor Law for the Twenty-First Century*, Cambridge University Press, 2019, 115-127.

Weil, David, “Understanding the Present and Future of Work in the Fissured Workplace Context”, *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 5(5), 2019, 147-165.

<Abstract>

A Study on Bargaining Unit Determination and the
Scope of Bargaining Obligations in Fissured
Employment Structures

— With Focus on Joint Employer and Mixed Bargaining Units
under the NLRA —

KWON, Ohseong^{*}

This article begins from the problem that, as fissured employment structures proliferate, a divergence emerges between the “formal employer” and the “substantive decision-maker,” thereby weakening the effectiveness of collective bargaining. In particular, where working conditions in subcontracting, outsourcing, dispatch work, corporate groups, franchising, or platform-based arrangements are substantively shaped by third parties other than the contracting employer—such as prime contractors, parent companies, or franchisors—an employer concept that is overly tethered to contractual form drives collective bargaining into dysfunction and generates gaps in responsibility for unfair labor practices. Against this backdrop, the article reconstitutes debates over joint employer status and mixed bargaining units under the U.S. National Labor Relations Act (NLRA) not as an importation of substantive criteria, but as a logic for allocating bargaining obligations, and draws comparative implications. In the United States, the joint-employer standard has shifted within a structure in which common-law control concepts, NLRB rulemaking and adjudication, and federal judicial review intersect; the invalidation of the 2023 final rule and the subsequent

^{*} Yonsei Law School, Professor

voluntary dismissal of the appeal, which left the 2020 rule operating as the practical reference point, illustrate the difficulty of converging on a stable, unitary standard for employer status.

The core of this article is to propose an interpretive model for the latter clause of Article 2(2) of the 2025 amended Trade Union and Labour Relations Adjustment Act, which provides that “even a person who is not a party to the employment contract shall, to the extent that the person is in a position to exercise substantive and specific control over and determine working conditions, be deemed an employer within that scope.” Rather than fragmenting the employer concept itself into a notion of a “partial employer,” the article argues that it is systemically coherent to recognize the third party’s employer status while, at the stage of legal effects, limiting the scope of collective bargaining obligations (and, further, responsibility) to the issue-specific range in which control and determination are substantively and concretely possible—i.e., a tiered model of limiting legal effects. In assessing whether such substantive and specific control and determination are possible, the article presents a typologized analytical framework that combines a “teleological approach,” which asks whether effective bargaining is feasible with the formal employer alone, with a “structural approach,” which examines who controls the decision-making structure for working conditions such as wages, staffing levels, and working hours. On this basis, the article seeks to indicate a direction for interpretation and application that prevents the expansion of employer status from being misconstrued as the automatic attribution of comprehensive bargaining duties, while securing the effectiveness of collective bargaining rights in fissured employment structures.

Key Words: Fissured Workplace, Joint Employer Doctrine, Collective Bargaining Obligations, Employer Status Expansion, Tiered Allocation of Legal Effects